KINX2005006947

취업규칙의 불이익 변경과 사회통념상의 합리성

대법원은 2004년 5월 14일자로 선고한 2002다23185 판결에서 '근로자의 집단적 동의를 받지 않아도 될 만한 사회통념상의 합리성이 있다고 볼 수 없어…상여금을 삭감하는 취업규칙의 효력을 인정할 수 없다'고 판시했다. 이 판결은 근로자에게 불리한 취업규칙의 변경일지라도 사회통념상 합리성이 있는 경우에는 근로자의 집단적 동의를 받지 않아도 유효하다는 전제 하에 판결을 내렸다는 점에서 논란의 소지가 있다. 특히 1989년 3월 29일 근로기준법 관련 규정을 개정하면서 '취업규칙을 근로자에게 불이익하게 변경하는 경우에는 (노조 또는 근로자대표의) 동의를 얻어야 한다'고 신설한 단서조항의 의미를 형해화시켰다는 점에서 문제가 있다는 것이 필자의 견해이다. 〈편집자〉

글 | 유 성 재
중앙대 법대 교수
yusj@cau.ac.kr

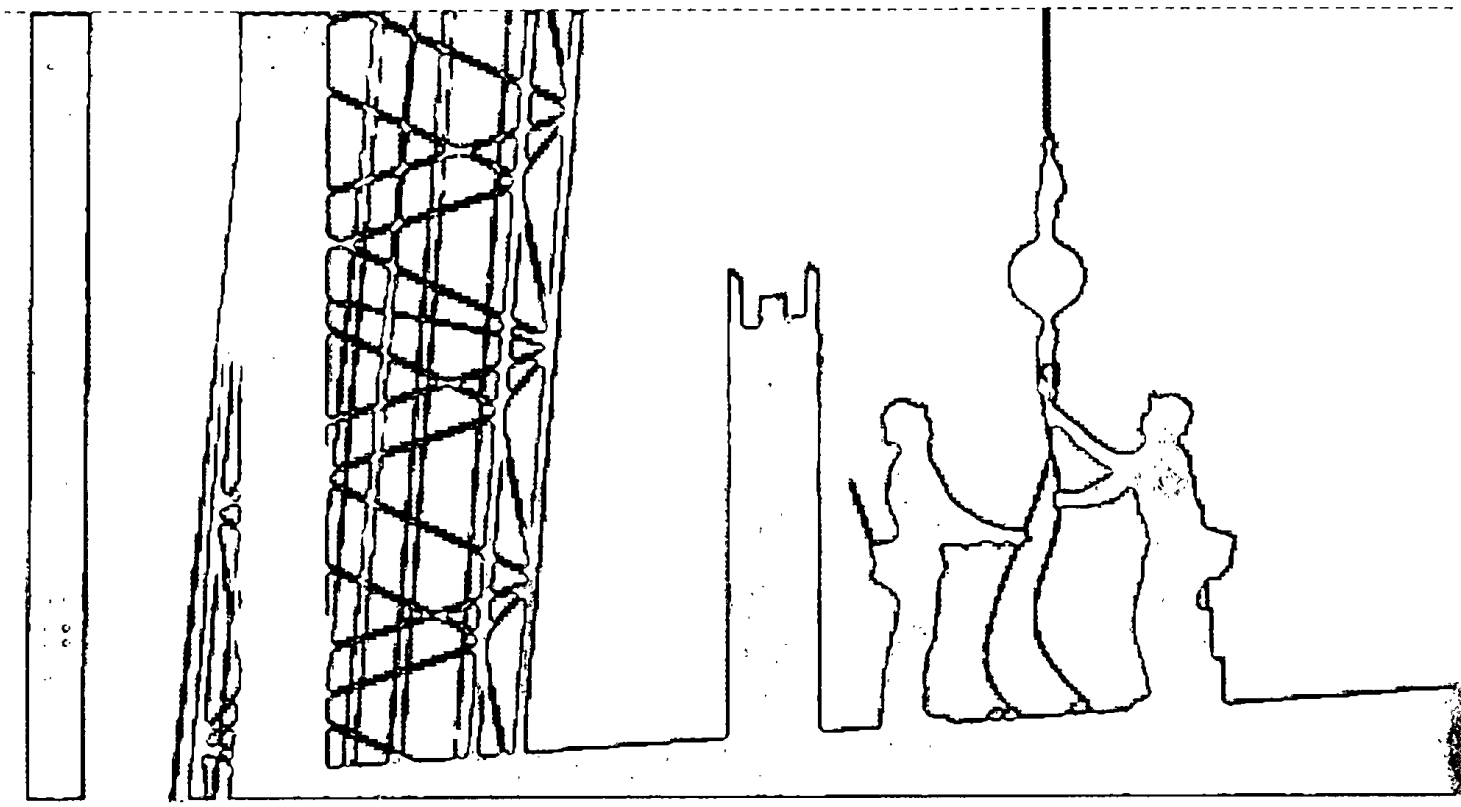
사건 개요

원고들은 피고회사에 건설사업부분의 근로자로서 근무하다가 1999년 3월 5일부터 1999년 12월 26일까지 사이에 퇴직하였다. 피고회사는 원고들에게 취업규칙 제38조 제2항의 규정에 따라 매년 설 3일전, 4월말, 6월말, 8월말, 추석 3일전, 12월말 등 6회에 걸쳐 기본급과 직무수당의 100%씩 연간 600%의 상여금을 지급하여 오다가 1997년 12월말 100%의 상여금을 지급하지 아니하기 시작하여 1999년 12월말까지 상여금을 지급하지 않았다.

한편 피고회사는 1998년 5월 24일부터 1998년 5월 29일까지 사이에 건설사업부문 전체 근로자 51명 중 44명을 참석하게 하여 그 중 39명으로부터 '외환위기 상황에서 경영위기 극복을 위하여 1998년에 지급될 상여금 전액(600%)을 삭감하는 데 동의한다'는 취지의 '상여금 삭감 동의 각서'를 받았다. 나아가 피고회사는 1998년 6월경 위 취업규칙의 상여금 조항을 삭제하였다.

쟁점 및 판결 요지

피고회사의 건설사업부문 근로자들이 1998년에 지급될 상여금을 삭감하는 데 동의하였고 이를 내용으로 하는 취업규칙의 변경이 유효하다는 점에 대하여는 이론이 없다. 문제는 근로자들의 동의가 1999년에 지급될 상여금을 삭



감하는 데 동의한 것으로 볼 수 있을 것인지, 만약 동의한 것으로 볼 수 없다면 근로자의 동의 없이 변경한 취업규칙은 유효한가와 그 요건은 무엇인지이다.[1)]

대법원은 근로자의 동의가 없는 취업규칙의 불이익 변경은 원칙적으로 허용되지 않는다고 하면서도, "당해 취업규칙의 작성 또는 변경이 그로 인하여 근로자가 입게 될 불이익의 정도를 고려하더라도 그 필요성 및 내용의 양면에서 보아 여전히 당해 조항의 법적 규범성을 시인할 수 있을 정도로 사회통념상 합리성이 있다고 인정되는 경우에는 종전 근로조건 또는 취업규칙의 적용을 받고 있던 근로자의 집단적 의사결정방법에 의한 동의가 없다는 이유만으로 그 적용을 부정할 수는 없다"고 하였다. 그러나 대법원은 대상판결의 경우에는 근로자의 집단적 동의를 받지 않아도 될 만한 사회통념상의 합리성이 있다고 볼 수 없어 1999년 이후의 상여금을 삭감하는 취업규칙의 효력을 인정할 수 없다고 보았다. 결론적으로 대법원은 취업규칙의 불이익 변경이 사회통념상 합리성이 있는 경우에는 근로자의 집단적 동의를 받지 않아도 유효하다고 보았다.

관련 규정

1989년 이전 근로기준법은 1953년 5월 10일

1) 대상판결에서는 근로자의 동의방식도 문제되었으나 아래에서는 취업규칙의 불이익 변경과 사회통념상의 합리성에 관한 문제에 대해서만 언급하기로 한다. 근로자의 동의방식에 대하여는 하경효, '취업규칙의 불이익 변경에 대한 근로자 동의의 의미와 방식', 노동법률 제61호(1995. 4.) 14면 이하 등 참조.

처음 제정될 당시부터 제95조(현행 제97조)에서 '사용자는 취업규칙의 작성 또는 변경에 관하여 당해 사업장에 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합, 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자의 과반수를 대표하는 자의 의견을 들어야 한다' 고 규정하고 있었다. 즉 1989년 3월 29일 전까지 근로기준법은 취업규칙을 근로자에게 유리하게 변경하는 경우는 물론 불이익하게 변경하는 경우에 대해서까지도 근로자대표의 동의가 아니라 근로자대표와 협의하는 것으로 족하다고 규정하고 있었다.

1989년 이후 그 후 1989년 3월 29일 동 조항에 '다만, 취업규칙을 근로자에게 불이익하게 변경하는 경우에는 그 동의를 얻어야 한다' 라는 단서가 추가되었으며, 동 단서는 공포와 함께 시행되었다. 따라서 1989년 3월 29일 신설된 단서에 의하면 취업규칙을 근로자에게 유리하게 변경하는 경우에는 근로자대표와의 협의로 충분하지만, 취업규칙을 근로자에게 불리하게 변경하는 경우에는 근로자대표의 동의를 받아야 비로소 그 효력이 인정된다.

일본 노동기준법 일본 노동기준법 제90조는 '사용자는 취업규칙의 작성 또는 변경에 관하여, 해당 사업장에노동자의 과반수로 조직한 노동조합이 있는 경우에 있어서는 그 노동조합, 노동자의 과반수로 조직한 노동조합이 없는 경우에 있어서는 노동자의 과반수를 대표한 자의 의견을 듣지 않으면 안된다' 라고 하고 있다. 이는 1989년 3월 29일 단서조항이 신설되기 전의 우리 근로기준법 제95조(현행 제97조)와 매우 유사하다.

판례

취업규칙의 불이익변경에 관한 법규정이 1989년 3월 29일 개정되었기 때문에 취업규칙의 불이익 변경에 관한 판례는 1989년 3월 29일 이전에 실시된 취업규칙의 불이익 변경에 관한 것과 그 이후에 실시된 취업규칙의 불이익 변경에 관한 것으로 나누어 살펴보기로 한다. 나아가 1989년 3월 29일에 개정되기 전의 법규정과 유사한 규정을 가지고 있는 일본 최고재판소의 판례도 함께 비교해 보기로 한다.

법개정 이전의 불이익 변경에 대한 판례 먼저 1989년 3월 29일 이전에 실시된 취업규칙의 불이익 변경과 관련하여 대법원[2]은 취업규칙의 불이익 변경과 관련하여 "근로기준법 제95조 제1항에 의한 취업규칙의 작성 또는 변경이 근로자가 가지고 있는 기득의 권리나 이익을 박탈하여 불이익한 근로조건을 부과하는 내용일 때에는 종전 근로조건 또는 취업규칙의 적용을 받고 있던 근로자집단의 집단의사결정방법에 의한 동의를 요하고 이러한 동의가 없이 작성, 변경된 취업규칙은 사회통념상 합리성이 있다고 인정될 만한 것이 아닌 한 무효"라고 하였다. 즉 근로기준법 제97조 제1항 단서

2) 대판 1990. 3. 13. 89다카24780. 이 판결은 1990년 3월 13일에 선고되었지만 1981년 1월 1일, 즉 근로기준법 제97조 제1항 단서가 신설되기 전에 실시된 취업규칙의 불이익 변경에 관한 사건이다.

'합리성 여부'와 '불이익 여부'라는 별개의 판단요소를 동일시하고 있는 판례의 입장은 옳지 않다. 왜냐하면 취업규칙의 불이익 변경에는 합리적인 불이익 변경과 불합리한 불이익 변경이 있을 수 있고, 취업규칙의 유리한 변경에도 합리적인 변경과 불합리한 변경이 있을 수 있을 뿐만 아니라, 양자를 동일시하는 것은 일반의 언어용례에도 맞지 않기 때문이다.

가 신설되기 전부터 이미 취업규칙의 불이익변경은 원칙적으로 근로자집단의 집단의사결정방법에 의한 동의를 요한다고 보았다. 다만, '사회통념상 합리성'이 있는 취업규칙의 불이익 변경은 근로자집단의 집단의사결정방법에 의한 동의 없이도 유효하다고 보았다. 그리고 취업규칙의 불이익 변경이 근로자집단의 집단의사결정방법에 의한 동의가 없이도 유효한 이유를 사회의 일반 통례에서 벗어나지 않은 제도는 근로자의 기존 근로조건상의 기득권을 침해하는 근로조건 변경이라고 단정할 수 없기 때문이라고 하였다.[3)]

법개정 이후의 불이익변경에 대한 판례1989년 3월 29일 근로기준법 제95조 제1항 단서(현행 근로기준법 제97조 제1항 단서)가 신설된 이후에도 취업규칙의 불이익 변경에 관한 대법원의 입장은 전혀 변경되지 않으며,[4)] 대상판결(대판 2004. 5. 14. 2002다23185) 역시 이러한 대법원의 입장과 일치한다.

일본 최고재판소의 판례 일본 최고재판소는 슈복버스사건(秋北バス事件)[5)]에서 취업규칙의 작성 또는 변경을 통하여 근로자에게 불리한 근로조건을 일방적으로 강요하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다고 하면서도, 근로조건의 집합적 처리, 특히 그 통일적이고 획일적인 결정을 기본 입장으로 하는 취업규칙의 성질에 비추어 당해 취업규칙 조항이 '합리적'인 경우에는 근로자의 동의가 없어도 효력이 있다고 보고 있어, 우리 판례와 동일한 입장을 취하고 있다. 일본 최고재판소는 이와 같은 판결 이후에도 취업규칙의 불이익 변경과 관련하여 이 판결의 입장을 계속 유지하고 있다.[6)]

학설

근로자의 집단적 동의를 얻지 못한 취업규칙의 불이익 변경과 '사회통념상의 합리성'의 관계에 대해서는 크게 두 학설이 대립하고 있다.

제1설 제1설[7)]은 "취업규칙 변경시 근로자들의

3) 대판 1978. 9. 12. 78다1046 등.

4) 대판 2004. 7. 22. 2002다59702 등.

5) 最判 1968. 12. 25., 民集 22?13?3459. 이에 대하여는 菅野和夫 · 西谷敏 · 荒木尙志 編, ??判例百選(第七版), 別册 ジュリスト No. 165, 54面 이하 참조.

6) 슈복버스사건 이후의 최고재판소 판결에 대하여는 菅野和夫(저)/이정(역), 일본 노동법의 이론과 실제, 2004, 128면 이하 참조.

7) 김형배, 노동법, 2004, 270면. 同旨: 이달휴, 취업규칙의 불이익 변경과 사회통념상의 합리성, 법과 사회 제22호(2002년 상반기), 161면 이하; 이병태, 최신 노동법, 2003, 943면 이하; 정진경, '근로조건의 불이익 변경', 노동법연구 제13호(2002년 하반기), 18면 이하; 최영호, '취업규칙의 불이익 변경', 노동법연구 제3호(1993년 12월), 172면.

의견청취만을 규정하였던 당시에 있어서는 사용자의 일방적인 취업규칙의 불이익 변경을 방지하고, 취업규칙을 통일적으로 적용하는 데 크게 기여했다고 평가된다. 그러나 근로기준법 제97조 1항 단서가 신설된 이후의 '취업규칙의 불이익 변경'의 문제는 오직 근로자들의 집단적 동의의 유무에 따라 판단되어야 한다. 왜냐하면 이 조항은 강행규정이기 때문이다"고 보는 견해이다. 이 학설에 의하면 '사회통념상의 합리성'에 관한 판례의 이론구성은 일본의 최고재판소의 판례이론을 수용한 것으로 1989년 단서조항을 신설하기 전까지는 우리 법원이 수용 가능한 해석방법 중의 하나였지만, 단서조항이 신설된 지금은 일본 최고재판소의 이러한 판례이론을 우리 법원이 수용하는 것은 불가능하다고 보고 있다. 한편 이러한 입장에 따르면서도 "경제환경 등의 변화로 인해 취업규칙의 변경이 불가피하다고 판단되는 경우에도 근로자가 이를 동의하지 않음으로써 발생할 수 있는 사용자의 부담을 조정"하기 위해, 근로자의 동의권 남용에 대해 권리남용이론을 적용할 것을 주장하는 견해[8]도 있다.

제2설 제2설[9]은 판례의 입장에 따라 사회통념상 합리성이 인정되는 취업규칙의 불이익 변경은 근로자의 집단적 동의를 얻지 않아도 유효하다고 보고, "이것은 법률이 불이익 변경의 요건으로 규정한 집단적 동의를 해석에 의하여 배제한 것이 아니라, 불이익 변경의 의미 내지 판단에 관한 해석상의 문제로서 변경의 내용이 사회통념상 합리적인 경우에는 불이익 변경에 해당되지 않는다고 해석한 것으로 보아야"한다는 견해이다.

사견

취업규칙의 불이익 변경과 사회통념상의 합리성과 관련하여 판례는 두 가지 전제에서 출발하고 있다. 하나는 불이익 변경 여부의 판단은 사회통념상의 합리성을 기준으로 판단하여야 한다는 것이고, 다른 하나는 사회통념상의 합리성이 있는 경우에는 근로자의 집단적 동의 없이도 취업규칙의 불이익 변경이 유효하다는 것이다. 아래에서는 두 문제를 분리하여 검토하기로 한다.

불이익 변경과 사회통념상의 합리성 판례[10]는 사회의 일반 통례에서 벗어난 불합리한 제도라고 볼 수 없는 취업규칙의 변경은 근로자의 기존 근로조건상의 기득권을 침해하는 근로조건 변경이라고 단정할 수 없다고 하고 있다. 한편 이들 판결들과는 달리 일부 대법원 판결[11]에서는 "취업규칙의 변경이 사회통념상 합리성이 있느냐의 여부와 근로자에게 불이익 하느냐 여부는…제반 사정을 종합하여 판단하여야 할 것이다"라고 하여, '사회통념상의 합리성 여부'와 '불이익 여부'가 별개의 요건인 것처럼 표현하

8) 하경효, 앞의 논문(註 1), 21면.
9) 임종률, 노동법, 2004, 335면 註 20 참조.
10) 대판 1978. 9. 12. 78다1046 등.
11) 대판 1997. 5. 16. 96다2507. 同旨: 대판 2000. 9. 29. 선고 99다45376.

면서 대법원의 1988년 5월 10일 판결을 인용하고 있다. 그러나 인용된 판결[12]은 "사회통례상 합리성이 있다고 인정되는 한 이를 들어 근로자에게만 불이익한 것이라고 속단할 수 없다 할 것이므로"라고 하여 앞의 판결에서와 같이 '사회통념상의 합리성'이 있으면 '불이익'에 해당하지 않는다고 보고 있다.

'합리성 여부'와 '불이익 여부'라는 별개의 판단요소를 동일시하고 있는 판례의 입장은 옳지 않다. 왜냐하면 취업규칙의 불이익 변경에는 합리적인 불이익 변경과 불합리한 불이익 변경이 있을 수 있고, 취업규칙의 유리한 변경에도 합리적인 변경과 불합리한 변경이 있을 수 있을 뿐만 아니라, 양자를 동일시하는 것은 일반의 언어용례에도 맞지 않기 때문이다.[13]

근로자의 집단적 동의와 사회통념상의 합리성

판례는 1989년 3월 29일 현행 근로기준법 제91조 제1항 단서(당시 제95조 제1항 단서)가 신설되기 전후를 불문하고 '사회통념상의 합리성'이 있으면 근로자의 집단적 동의를 받지 않아도 취업규칙의 불이익 변경이 유효하다고 보고 있다. 이러한 판례의 입장은 위 제1설이 주장하는 바와 같이 1989년 단서조항을 신설하기 전까지는 우리에게도 가능한 해석방법 중의 하나가 될 수 있다고 본다. 그러나 단서조항이 신설된 이후의 이러한 법적용은 근로기준법 제97조 제1항 단서의 의미를 형해화(形骸化)시키는 것으로 법관에 의한 법형성의 한계를 일탈한 것이다.

그러나 합리적인 취업규칙의 변경에 대하여 근로자가 동의권을 남용하는 경우에 대하여는 권리남용의 법리를 적용하여 그 효력을 인정할 필요가 있다고 본다.[14] 물론 권리남용의 법리가 적용되기 위한 요건[15]과 '사회통념상의 합리성'의 판단기준은 일치하지 않는다.

결론적으로 근로기준법 제97조 제1항 단서가 신설되었음에도 불구하고 '사회통념상의 합리성'이 있으면 근로자의 집단적 동의 없이도 취업규칙의 불이익 변경이 유효하다고 보는 판례이론은 옳지 않다.

판례는 1989년 3월 29일 현행 근로기준법 제91조 제1항 단서(당시 제95조 제1항 단서)가 신설되기 전후를 불문하고 '사회통념상의 합리성'이 있으면 근로자의 집단적 동의를 받지 않아도 취업규칙의 불이익 변경이 유효하다고 보고 있다. 단서조항이 신설된 이후의 이러한 법적용은 근로기준법 제97조 제1항 단서의 의미를 형해화(形骸化)시키는 것으로 법관에 의한 법형성의 한계를 일탈한 것이다.

12) 대판 1988. 5. 10. 87다카2853.

13) 동아 「새국어사전」에서는 합리성을 '행위가 능률적으로 행하여지거나 사태가 목적에 적합한 성질'이라고 정의하고 있고, 동녘 「철학대사전」에서는 '최선의 결과를 얻기 위해 효과적인 수단과 방법을 찾는 것'이라고 정의하고 있다.

14) 同旨: 하경효, 앞의 논문(註 1), 21면.

15) 판례(대판 1998. 6. 26. 97다42823)에 의하면 권리남용이 인정되기 위해서는 객관적으로 그 권리행사가 사회질서에 위반될 뿐만 아니라 "주관적으로 그 권리행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐, 행사하는 사람에게 아무런 이익이 없는 경우"이어야 한다.